

1500367-34.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. CONFISSÃO DA AUTORIA DELITIVA DURANTE A INQUIRÇÃO, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA, EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL. EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o direito ao silêncio é um consectário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500367-34.2022.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-34.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2015033/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 22495557 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 88/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2015033 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 88/22/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR MANOEL DOS SANTOS DE ALENCAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

VICTOR MANOEL DOS SANTOS DE ALENCAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 1-3):

no dia 17 de janeiro de 2022, por volta de 17h15min, na Avenida Mogi Guaçu, nº 1470, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, VICTOR MANOEL DOS SANTOS DE ALENCAR, qualificado a fls. 16, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 06 porções de maconha, assim como guardava, também para fins de

comercialização, 16 porções de maconha, com peso total aproximado de 20 gramas, e 66 microtubos contendo cocaína, pesando cerca de 42 gramas (conforme auto de exibição e a apreensão de fls. 09/10 e autos de constatação preliminar a fls. 14/15), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou sua defesa prévia (fls. 64-67). A denúncia foi recebida (fls. 74-75), o réu foi citado e intimado para audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, em debates orais, as partes se manifestaram.

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia, alegando que a versão dos policiais é coesa e harmônica, enquanto a do réu não é crível. Na dosimetria, pediu o afastamento do redutor do art. 33, §4º, uma vez que o réu já possui envolvimento com atividades ilícitas, possuindo condenação confirmada em segunda instância, além da fixação do regime inicial fechado e afastamento dos benefícios legais.

A defesa, por sua vez, pediu a improcedência da ação, alegando que as testemunhas de acusação não conseguiram comprovar a culpa do réu, requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06.

É o relatório.

DECIDO.

O caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública. No caso em exame, há prova da materialidade do crime, que foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10-11, auto de exibição e apreensão de fls. 12-13 e laudo de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 147-149 e 150-152.

Por outro lado, a autoria é incerta. Vejamos.

A testemunha em comum, o guarda municipal Alberto Firmino dos Santos, disse, em juízo, que na data dos fatos estava em patrulhamento no bairro, local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que o réu mora logo em frente. Quando passaram por ali viram o réu atravessando a rua, e ele, quando viu a viatura, tentou dispensar algo no chão, sendo abordado. Com ele foi apreendida uma porção de maconha, e, bem próximo ao local, mais outras cinco porções da droga. Indagado, o réu informou que, além das seis porções de maconha apreendidas, tinha mais de drogas guardadas, escondidas por ali, indicando o local, que ficava cerca de 20 metros, e lá foi encontrado o restante da droga. Após, foram até a casa dele buscar documentos e lá localizaram mais 60 reais que também foram apreendidos. Reiterou que o acusado indicou que a cocaína estaria em um local próximo a uma rotatória, em um arbusto. Disse que o réu não foi até o local indicar, apenas falou mais ou menos onde estaria e que confessou que a droga era dele. O réu disse que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de entorpecentes. O depoente disse que conhecia o réu por ele morar na frente do ponto de drogas e sempre andar com pessoas ligadas ao tráfico, mas nada tinha contra ele. A droga encontrada estava há cerca de uns 15 metros do local de onde foi feita a abordagem. Do local onde o réu foi abordado dava para ver onde estavam as drogas, apesar da distância.

A testemunha em comum, o guarda municipal Jairo José dos Santos, disse, em juízo, que na data estava patrulhando pelo bairro e viram o réu atravessando a avenida, tendo dispensado no chão 5 porções de maconha, por isso o abordaram. Questionado, o réu confessou que a droga dispensada era dele e informou que tinha mais droga guardada em um local próximo, indicando onde os policiais a encontrariam. No local

indicado, havia mais algumas porções de maconha e diversas outras porções de cocaína. Como ele estava sem documento foram até a casa dele e pegaram documentos, apreendendo também 66 reais. A embalagem da maconha encontrada no esconderijo era idêntica à maconha encontrada com o réu. Conhecia o acusado pois ele morava na frente de um ponto de venda de drogas. Nada tinha contra o réu. O réu quem apontou que o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico, havia mais dinheiro no local, mas era proveniente do trabalho da esposa do acusado. A árvore em que encontraram os entorpecentes estava há cerca de 15 a 20 metros do local. Na residência só foi localizada os 56 reais.

A testemunha de defesa Célio Paulino Martins disse que conhece o réu desde pequeno, e que o réu tem problemas de saúde, que já o buscou na UNICAMP. Soube que o réu fumava maconha pois sentia muitas dores. Sabe que a conduta do réu é boa, nada sabe que o possa desabonar.

A testemunha de defesa Amanda Alves Maia disse que é amiga do réu há mais de 15 anos. Sabe dizer que ele tem problema de saúde, artrite, um problema nos ossos e que sente dores por causa disso, fazendo tratamento na UNICAMP há uns 6 anos. O réu VICTOR MANOEL DOS SANTOS DE ALENCAR disse que a acusação é falsa. Alegou que estava em sua casa, foi fazer entrega de trufas para sua mãe, e, após fazer a entrega, pegou 100 reais emprestados de sua genitora, foi até a padaria, comprou um salgado e uma coca-cola, e foi até a casa de sua namorada. Ficou lá por um tempo, e após, decidiu ir até um ponto de tráfico comprar drogas. Comprou 6 porções de maconha, bolou um cigarro, mas quando apareceu a guarda ficou com medo e jogou 5 porções de maconha no chão. Os policiais começaram a fazer averiguações pelo local e encontraram o restante da droga há uns 30 metros do local. Nega ter assumido a propriedade das demais drogas, apenas das 6 porções de maconha. Afirmou que não mora próximo ao local dos fatos, quem mora ali é sua esposa. Reiterou que no dia tinha 100 reais, foi até a padaria e gastou uns 14 reais, após foi até a casa de sua namorada, ficou lá um pouco, e foi comprar drogas. Os 56 reais apreendidos estavam com o réu, não na casa dele, onde os policiais foram e não encontraram nada. Não havia dinheiro dele na casa da esposa, apenas dinheiro que sua companheira ganhava vendendo jóias.

Pois bem, respeitado o entendimento do Ministério Público, entendo que o caso é de absolvição, pelos motivos a seguir expostos.

Não há nos autos provas suficientes que as 16 porções de maconha e 66 microtubos contendo cocaína sejam de propriedade do acusado. Isso porque se extrai do processo que os policiais apreenderam diretamente com o acusado uma única porção de maconha, e viram quando o acusado dispensou 5 porções de maconha, fato por ele admitido em juízo, mas não viram ele próximo ao local onde os demais entorpecentes foram localizados. Não há qualquer prova nos autos de que as 16 porções de maconha e os 66 microtubos com cocaína encontrados ali fossem do acusado.

O que há nos autos é somente uma aventada confissão informal, que teria sido feita aos policiais no local dos fatos, mas que não foi repetida em solo policial e veementemente negada em juízo.

Deve-se observar que a suposta confissão informal não possui valor probatório no processo penal sem que se tenha provas de que o acusado foi previamente advertido sobre o direito ao silêncio, conforme tem entendido o Supremo Tribunal Federal (RHC 170843 AgR/SP, julgado em junho de 2021).

Este entendimento tem sido adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme se verifica em ilustrativo voto proferido pelo Desembargador Relator Marcos Alexandre Coelho Zilli, da 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556:

2.2.2.2. O direito ao silêncio no sistema brasileiro:

O direito ao silêncio, que encontra albergue no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, como projeção do direito a não autoincriminação, tem há tempos tomado o foco de atenção da jurisprudência nacional. No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, cristalizou-se o entendimento de que nenhuma pessoa, uma vez confrontada com a atividade

persecutória estatal, poderá ser compelida a produzir prova contra si mesma. Nesse sentido:

"O direito à não autoincriminação consiste na prerrogativa do investigado ou acusado a negar-se a produzir provas contra si mesmo, e a não ter a negativa interpretada contra si. No caso, interessa o direito ao silêncio, o aspecto mais corrente do direito à não autoincriminação. Por projeção, o direito ao silêncio consistente na prerrogativa do implicado a recusar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade." (STF, ADPF nº 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J: 14/06/2018, DJe: 22/05/2019).

No mesmo sentido, converge o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. CONFISSÃO DA AUTORIA DELITIVA DURANTE A INQUIRÇÃO, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA, EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL. EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras. 2. Consequência lógica da aplicação do direito ao silêncio é a exigência que se impõe às autoridades, policiais e judiciais, da advertência ao réu de seu direito de permanecer em silêncio (art. 186, caput, CPP), sob pena de nulidade. Não fosse assim, na prática, o princípio jamais seria observado, como não o foi no famoso e paradigmático precedente da jurisprudência norte americana, Miranda vs. Arizona, em 1966, no qual se anulou a confissão prestada pelo réu, por ausência de informação de seus direitos constitucionais, entre os quais o de permanecer calado. Nesse sentido, STF HC nº 78.708-1/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.4.1999. Mais que uma exigência ética de observância do Direito, a informação da existência do direito ao silêncio presta-se também a evitar a prática de métodos extorsivos da confissão, que vem a ser a ratio essendi da norma (Curso de processo penal/Eugênio Pacelli. 22. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 386).

3. "A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo" (AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

4. Na hipótese, a defesa logrou demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, uma vez que, em ofensa ao princípio da não autoincriminação, é réu em uma ação penal cuja denúncia se baseia, principalmente, em confissão por ele feita na condição de testemunha noutro processo criminal, oportunidade na qual, embora formalmente advertido da obrigação de dizer a verdade, a Magistrada que conduziu a oitiva, em vez de advertilo sobre o direito de permanecer em silêncio, iniciou verdadeiro interrogatório, pressionando-o a se autoincriminar.

5. "Se o indivíduo é convocado para depor como testemunha em uma investigação e, durante o seu depoimento, acaba confessando um crime, essa confissão não é válida se a autoridade que presidia o ato não o advertiu previamente de que ele não era obrigado a produzir prova contra si mesmo, tendo o direito de permanecer calado" (STF. Segunda Turma. RHC n. 122.279/RJ, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 12/8/2014 - Informativo de Jurisprudência n. 754 do STF).

6. Recurso ordinário em habeas corpus provido, a fim de anular as provas obtidas mediante violação do direito ao silêncio, determinando o seu desentranhamento dos autos de n. 0025326-50.2016.8.26.0050, em curso perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. (STJ, RHC nº 131.030, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J: 03/11/2020, DJe: 16/11/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DIREITO AO SILÊNCIO. AMPLITUDE. ADVERTÊNCIA JUDICIAL. REFLEXOS NA VOLUNTARIEDADE DO DEPOIMENTO. PROVA ILÍCITA. PREJUÍZO AO ACUSADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. A busca da verdade no processo penal sujeita-se a limitações e regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional, cujo objetivo maior é a descoberta da verdade processual e constitucionalmente válida, a partir da qual se possa ou aplicar uma sanção àquele que se comprovou culpado e responsável pela prática de um delito, ou declarar sua inocência quando as evidências não autorizarem o julgamento favorável à pretensão punitiva.
2. Uma dessas limitações, de feição ética, ao poder-dever de investigar a verdade dos fatos é, precisamente, a impossibilidade de obrigar ou induzir o réu a colaborar com sua própria condenação, por meio de declarações ou fornecimento de provas que contribuam para comprovar a acusação que pesa em seu desfavor. Daí por que a Constituição assegura ao preso o "direito de permanecer calado" (art. 5º, LXIII), cuja leitura meramente literal poderia levar à conclusão de que somente o acusado, e mais ainda o preso, é titular do direito a não produzir prova contra si.
3. Na verdade, qualquer pessoa, ao confrontar-se com o Estado em sua atividade persecutória, deve ter a proteção jurídica contra eventual tentativa de induzir-lhe a produção de prova favorável ao interesse punitivo estatal, especialmente se do silêncio puder decorrer responsabilização penal do próprio depoente.
4. A moldura fática delineada no acórdão impugnado explicita que o Magistrado, antes de iniciar o depoimento do adolescente, advertiu-o, após externado seu desejo de permanecer em silêncio, de que poderia "ser novamente apreendido se não falasse a verdade".
5. A hipótese retrata situação em que o destinatário da advertência foi chamado a depor, como testemunha de acusação, e era o adolescente que acompanhava o paciente quando este foi autuado em flagrante, por estar supostamente transportando expressiva quantidade de maconha dentro do automóvel por ele conduzido.
6. Desde o início da persecução penal, a controvérsia central cingiu-se à definição sobre a propriedade dessa droga, pois nenhum dos dois ocupantes do automóvel - o paciente e o seu carona, o referido adolescente - assumiu a posse da embalagem encontrada no interior do veículo.
7. Assim, e mais ainda por tal circunstância, a advertência da autoridade judiciária feita ao depoente viciou o ato de vontade e direcionou o teor das declarações.
8. É ilícita, portanto, a prova produzida e, por ter sido desfavorável ao réu e ter-lhe causado notório e inquestionável prejuízo, há de ser afastada, com a consequente anulação da sentença condenatória, de modo a que seja refeito o ato decisório, sem que conste, do seu teor e da argumentação judicial, esse depoimento. Isso porque se nota, sem dúvida alguma, que a sentença faz alusão a outras evidências e a provas produzidas em juízo, de sorte a não autorizar-se a acolhida do pedido principal formulado na impetração, de absolvição do paciente.
9. Ordem concedida em parte, a fim de anular o processo a partir, inclusive, da sentença. Deve o juiz desentranhar dos autos o depoimento do adolescente M. S. da C, colhido judicialmente, e proferir nova sentença, com o conjunto das provas restantes.

(STJ, HC 330.559/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J: 25/9/2018, DJe: 10/10/2018).

Importante salientar que, para além da observância do direito ao silêncio no âmbito dos interrogatórios formais, ou seja, aqueles prestados perante as autoridades policial e judiciária, em vários precedentes, o Supremo Tribunal Federal, tal como decidido pela Suprema Corte norte-americana no caso *Miranda vs. Arizona*, tem reconhecido que a advertência do direito ao silêncio deve ser realizada também pelos policiais responsáveis pela voz de prisão.

No julgamento do HC nº 80.949/SP, em 30 de outubro de 2001, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a falta de advertência do direito ao silêncio pelos policiais, quando de conversa

informal com um preso, havia sido ilegal qualificando a prova obtida como ilícita. O caso envolveu situação de preso temporário que foi levado até uma sala nas dependências do distrito policial onde passou a travar uma conversa com os agentes policiais que tomaram a cautela gravá-la. Entendeu-se no caso que a ausência de advertência do direito ao silêncio havia maculado a prova obtida. Nesse sentido: O interrogatório é a única forma legal de tomada, no inquérito policial, de declarações do indiciado: nele, não há espaço para acolher como declarações do indiciado e menos ainda para validar eventual confissão nelas contida o registro, gravado ou não, de “conversa informal” dele com policiais.

A Constituição, no entanto, aditou outra exigência essencial à valoração no processo de declarações do indiciado ou do réu, ao erigir, como garantia fundamental do acusado:

Art. 5º (...) LXIII. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado... Elevando aí o nemo tenetur se detegere à alçada de garantia fundamental além da inconstitucionalidade superveniente, consensualmente admitida, da parte final do art. 186, C. Pr. Pen a Constituição na linha da construção da jurisprudência americana, a partir dos famosos casos Escobedo vs. Illinois (378 U.S. 478 1964) e Miranda vs. Arizona (384 U.S. 436 (1969) impõe ao inquiridor, na polícia ou em juízo, o dever de advertência ao interrogado de seu privilégio contra a auto-incriminação.

A falta de advertência e, como é óbvio, da sua documentação formal faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o acusado, ainda quando observadas as formalidades procedimentais do interrogatório.

Dezoito anos após a prolação do referido julgado, nos autos da Reclamação nº 33.711, julgada em 11 de junho de 2019, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a nulidade do interrogatório o qual havia sido denominado de “entrevista” pela Polícia Federal. Naquele caso, os agentes policiais, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, realizaram várias perguntas ao acusado e cujas respostas foram reduzidas a termo. Mais uma vez entendeu-se que a providência havia desrespeitado o direito ao silêncio pela omissão nas advertências.

No caso em análise, a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ocorreu com a realização de interrogatório travestido de “entrevista”, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes acima transcritos. Observo, portanto, a violação às decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, na medida em que utilizada técnica de interrogatório forçado proibida a partir do julgamento das referidas ações. Há a evidente tentativa de se contornar a proibição estabelecida pelo STF em favor dos direitos e garantias fundamentais das pessoas investigadas.

(...)

Cumprе relembrar o entendimento firmado no julgamento do caso Miranda v. Arizona, citado nos votos que proferi nas ADPFs 395 e 444. No caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a acusação não poderia se utilizar de declarações obtidas por agentes policiais após a apreensão ou detenção de acusados, sem a demonstração da utilização de procedimentos que evidenciassem a proteção contra a autoincriminação prevista na Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos.

Por fim, em recente acórdão prolatado nos autos do RHC nº 192798 AGR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado nas sessões virtuais de 12 a 23 de fevereiro do corrente ano, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito ao silêncio havia sido violado em razão da utilização de confissão informal como elemento de prova. A situação envolveu o contexto de prisão em flagrante quando o suposto agente confessou, informalmente, a prática do delito de associação para o tráfico de drogas. Durante o processo, apurou-se que os policiais responsáveis pela prisão do paciente não haviam observado o comando constitucional assecuratório do direito ao silêncio e a imperatividade, dele decorrente, das

necessárias advertências. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe a o Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido.

(...)

(...). De se ressaltar que é irrelevante a ausência de norma processual que estabeleça o dever aos agentes policiais de previamente cientificar a pessoa presa dos termos daquele direito. Isto porque, tal direito está previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e no art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos, normas que, portanto, possuem eficácia imediata, não dependendo de normas infraconstitucionais para sua regulamentação. O direito ao silêncio, conforme assente na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana e do Supremo Tribunal Federal, não se restringe à fase processual, nem aos interrogatórios formais, mas deve ser observado por todos os órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos, inclusive aos agentes policiais quando da prisão do suspeito ou do acusado (grifei).

Nesse sentido, é a lição de Maria Elisabeth Queijo:

A rigor, a advertência deve ser formulada quando da prisão do suspeito ou acusado, para que desde logo fique ciente de seus direitos, entre eles o de não se autoincriminar. Referida advertência deverá ser formulada, mesmo que o suspeito ou acusado não venha a ser, de pronto, indagado sobre os fatos. Desde logo, a advertência evitará a tomada de declarações com violação do nemo tenetur se detegere e preservará sua liberdade de autodeterminação.

Na mesma esteira, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Palamara Iribarne vs. Chile, julgado em 22 de novembro de 2005, reconheceu a violação ao direito ao silêncio. Isso porque, ao longo de dois processos instaurados Iribarne havia comparecido às dependências do Ministério Público onde prestou declarações que não havia sido precedidas do direito ao silêncio. Nesse sentido:

Además, la Corte debe resaltar que durante los dos procesos penales militares el señor Palamara Iribarne rindió declaración ante el Fiscal en diversas ocasiones. En relación con dichas declaraciones la Corte realiza dos observaciones. Por un lado, en ninguna de ellas el señor Palamara Iribarne declaró ante un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, lo que vulnera el artículo 8.1 de la Convención. Por otra parte, en las diferentes citaciones a declarar emitidas por el Fiscal no se indicó el motivo para solicitar su comparecencia ni el tema sobre el que versaría dicha declaración, así como tampoco se le realizaron las previsiones sobre su derecho a no declarar contra sí mismo. Por la propia estructura del proceso penal militar y la consiguiente falta de imparcialidad el Fiscal Naval no puede ser asimilado al juez que garantiza el derecho a ser oído. Por ello, el Estado violó el artículo 8.1 y 8.2.g) de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne.

Por derradeiro, tratando-se de prova ilícita, a consequência é a sua imprestabilidade para fins processuais. Esta foi a formatação adotada pelo legislador constituinte ao proclamar a proibição das provas ilícitas. Mais do que isto, a inserção da cláusula da inadmissibilidade das provas ilícitas é uma vigorosa mensagem do apreço pelo regime das liberdades individuais. O que se proíbe é a concretização ilícita do poder-dever punitivo na busca por provas reveladoras da responsabilidade penal de alguém. O mandamento é, enfim, imperativo dele não

podendo se afastar o operador do direito na realização diária de sua atividade jurisdicional."

(TJSP; Apelação Criminal 1500308-45.2020.8.26.0556; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Ademais, ainda que se admitisse a legalidade da confissão informal realizada por acusado aos policiais militares sem que se prove ter sido ele advertido quanto ao direito ao silêncio, tal fato, isoladamente, como ocorre nos autos, não é capaz de embasar um decreto condenatório.

Neste sentido também entende o TJSP:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. Condenação contrária à evidência dos autos reconhecida quanto ao segundo delito. Vínculo associativo, com características de estabilidade e permanência, não demonstrado. Condenação lastreada unicamente na confissão informal supostamente realizada pelo corréu aos policiais, que não se presta para embasar o decreto condenatório. Extensão dos efeitos da decisão ao corréu, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO.

(TJSP; Revisão Criminal 2293004-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/11/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO. 1) Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Materialidade demonstrada, porém, autoria duvidosa. Policiais que não encontraram droga com o réu, nem presenciaram ato de mercancia. Divergências relevantes nos depoimentos prestados. Negativa do réu em juízo. Confissão informal que não se presta a embasar édito condenatório. Insuficiência probatória. Absolvição (art. 386, VII, CPP). 2) Recepção (art. 180, caput, CP). Autoria e materialidade demonstradas à suficiência. Réu encontrado em posse do aparelho furtado e que não comprovou a origem lícita do bem. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Agravante do art. 61, II, j, do CP afastada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Sentença reformada em parte. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu parcialmente provido, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas (art. 386, VII, CPP), mantida a condenação pela recepção. Determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.

(TJSP; Apelação Criminal 1503802-75.2020.8.26.0536; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Assim, desprezada a alegada confissão informal que teria sido feita pelo réu aos policiais apenas no momento de sua abordagem, não há nos autos nem uma única prova que o ligue aos entorpecentes apreendidos no local, tão somente às seis porções de maconha, uma que estava com ele, e outras cinco que os policiais o viram arremessar ao solo.

Vale dizer ainda que a alegação feita de que os entorpecentes com ele apreendidos eram idênticos aos que foram posteriormente encontrados também não é suficiente para demonstrar a traficância. Afinal, nem ao menos se comprovou que as porções eram de fato idênticas, e, além disso, tendo o réu admitido que havia adquirido as porções de maconha nas proximidades, é possível que as drogas encontradas pelos policiais pertencessem ao mesmo traficante.

Assim, considerando apenas as seis porções de maconha apreendidas com o acusado, tenho que sua alegação de que elas se destinavam ao uso próprio não foram suficientemente rebatidas. Vejamos.

O peso total da maconha apreendida, isto é, das 22 porções, foi de 20,8g, ou seja,

menos de 1g por porção. Assim, embora as 6 porções apreendidas com o réu não tenham sido pesadas separadamente, razoável supor que possuíam peso líquido de menos de 6g.

O art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que:

Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Ressalto que conforme Estudo Técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei n. 11.343/2006, do MPPR disponível em (https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf) a quantidade compatível com o uso diário de maconha é 2,5 gramas.

Desse modo, a quantidade apreendida (cerca de 6g de maconha) seria suficiente para 2 ou 3 dias de uso, o que é compatível com a versão apresentada pelo acusado.

Além disso, na residência do acusado não foram encontradas balanças, anotações, embalagens, ou quaisquer outros objetos comumente relacionados ao tráfico de drogas.

Quanto ao dinheiro apreendido, nada foi encontrado com ele, tendo sido localizada a quantia de R\$56,00 em sua casa, valor que não se mostra exorbitante.

Por fim, reitera-se que os policiais disseram não ter visto o acusado em qualquer ato de mercancia.

Assim, consideradas todas essas circunstâncias, entendo que a versão do réu, de que os entorpecentes se destinavam apenas ao consumo próprio, não foi infirmada pelo contexto probatório amealhado a estes autos, sendo de rigor a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

E assim dispõe o referido artigo:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Ocorre que, respeitado entendimento contrário que obviamente não se desconhece, e também revendo posição anteriormente já adotada por este juízo, entendo que referida criminalização é inconstitucional, por estabelecer injustificada e desproporcional restrição às liberdades individuais.

Dispõe o art. 5º, caput, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]

Evidentemente que, assim como os demais direitos e garantias constitucionais, a liberdade individual não é absoluta, podendo ser restringida pela lei, o que se justifica pela promoção do bem comum. Neste sentido, a lei deve estabelecer restrições à autonomia individual, de modo a impedir que o exercício desregrado da liberdade de um particular possa colocar em risco a sociedade que o cerca. Por tais razões, o Direito Penal, que impõe as mais severas restrições às

liberdades em nosso ordenamento jurídico, reserva-se somente para os casos em que haja repercussão social grave, não podendo ser acionado em situações nas quais a conduta lesa tão somente o próprio indivíduo, como no crime em análise, ao que se convencionou chamar de “princípio da alteridade”.

Neste sentido, assim leciona Nilo Batista:

No direito penal, à conduta do sujeito autor do crime deve relacionar-se, como signo do outro sujeito, o bem jurídico (que era objeto da proteção penal e foi ofendido pelo crime – e por isso chamado de objeto jurídico do crime). Como ensina Roxin, “só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o direito penal só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está legitimado e nem é adequado para a educação moral dos cidadãos.” À conduta puramente interna ou puramente individual – seja pecaminosa, imoral, escandalosa ou diferente – falta a lesividade que pode legitimar a intervenção penal.

[...]

No Brasil, o artigo 28 da Lei 11.343, de 23.ago.2006, incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais.

É, por tais razões, que o Direito Penal brasileiro não pune a embriaguez alcoólica, exceto quando relacionada à direção de veículo automotor, por colocar em risco a segurança dos demais motoristas e transeuntes (art. 306 do CTB). Também por isso, não se pune a autolesão, exceto quando efetuada com o intuito de fraudar seguro, por repercutir na esfera patrimonial de terceiros (art. 171, §2º, inc. V, do CP). Assim, fixadas tais premissas, forçoso convir que o porte de drogas para uso próprio diz respeito apenas ao usuário, não lesando bem jurídico de qualquer outra pessoa.

É certo que o tráfico de drogas traz inúmeros prejuízos à sociedade, porém, tal conduta segue criminalizada, não se confundindo a figura do usuário, como no presente caso, com a do traficante.

Não se nega, obviamente, os malefícios que os entorpecentes causam ao usuário, sejam os prejuízos à sua saúde como os prejuízos para sua vida social, muitas vezes decorrentes do vício. Ocorre que tais prejuízos também são observados diariamente no uso abusivo de tabaco ou álcool, por exemplo, sem que se cogite a criminalização de seu uso, justamente pelos motivos acima elencados.

Percebe-se, portanto, que não há razoabilidade na criminalização do porte para uso próprio de determinados entorpecentes e não de outros, havendo, em realidade, uma pretensão estatal de impor padrão de conduta moral supostamente majoritário, objetivo para o qual não se mostra proporcional ou adequada a utilização do Direito Penal.

Por tudo isso, entende-se que a criminalização do uso de drogas, ou do porte para o uso delas, configura restrição indevida da liberdade, com violação ao que dispõe o artigo 3º, IV, da Constituição Federal, dispositivo que veda todas as formas de discriminação.

Por fim, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal já se debruça sobre o assunto, sendo que no julgamento do RE 635659 o relator Ministro Gilmar Mendes já votou pela inconstitucionalidade do referido tipo penal, tendo sido parcialmente acompanhado pelos Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, os quais restringiram a declaração de inconstitucionalidade à maconha por se tratar da droga objeto do caso concreto em julgamento naquela corte.

Pelo exposto, a absolvição do réu quanto ao crime de porte de drogas para uso próprio é medida que se impõe, ante a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06.

Por todo o exposto acima, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER VICTOR MANOEL DOS SANTOS DE ALENCAR das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do art. 386, inc. VII (com relação ao tráfico) e inc. III (com relação ao porte para consumo), do CPP.

Expeça-se alvará de soltura.
Oportunamente, arquivem-se.
P.I.C

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA